

CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL – ESTUPRO II

ESTUPRO

Pontos relevantes

1. Para configurar o delito, é necessário haver contato físico entre o estuprador e a vítima?

A conjunção carnal é a introdução do pênis na vagina e, obviamente, é necessário que haja esse contato físico. Com relação a atos libidinosos, nem sempre ocorrerá o contato físico. Por exemplo, o estuprador que, mediante grave ameaça, coloque uma arma na cabeça da vítima e determine que ela pratique automasturbação. Não houve contato físico entre o estuprador e a vítima, mas esta foi vítima de estupro, porque o agente a constrangeu mediante grave ameaça para que ela viesse a praticar um ato libidinoso. O contato físico ocorre diante da conjunção carnal, mas o delito de estupro não exige que haja o contato físico entre o estuprador e a vítima.

2. Configura estupro constranger alguém a assistir a uma relação sexual consentida?

A e B praticam uma relação sexual consentida, ambos obrigam a uma terceira pessoa a assisti-los para satisfazer a sua lascívia. A terceira pessoa, C, assiste a prática sexual de A e B.

Nesse caso não há crime de estupro, não é uma conduta atípica, é uma conduta típica: o agente vai responder pelo crime dependendo da idade da vítima. Se a vítima for menor de 14 anos (delito do art. 218-A do Código Penal), se a vítima for de idade igual ou maior de 14 anos (delito do art. 146 do CP). Não há um crime específico nessa situação.

3. Recusa da vítima deve ser séria e objetiva

A doutrina traz esse ponto relevante porque há uma recusa que faz parte do jogo, do flerte, “digo não, mas quero”, portanto, segundo a doutrina, a recusa da vítima deve ser séria e objetiva. Havendo constrangimento a seguir a essa recusa, configura-se o crime de estupro. Não que seja exigido que haja essa recusa, que essa recusa seja verbal, uma recusa expressa pode ser tácita desde que séria e objetiva a ponto de alguns doutrinadores dizerem que, se essa recusa não for séria e objetiva, pode o agente incidir em erro de tipo que excluiria o dolo, permite a punição por culpa se for um erro vencível, inescusável. O crime de estupro não permite a modalidade culposa, portanto o agente ficaria absolutamente impune em razão desse erro de tipo.



ANOTAÇÕES

4. Alternância de vontade da vítima

Supondo que, no início do estupro, houve constrangimento pela violência ou grave ameaça contra a vítima. A vítima está praticando a conjunção carnal, só que, durante o ato sexual, a vítima muda a sua vontade: se no início ela tinha sido constrangida, ela agora quer fazer a prática sexual. Nesse caso a doutrina considera que o agente não responde pelo estupro, que é uma conduta atípica, ainda que pese que, inicialmente, tivesse sido praticada violência e constrangimento e que o consentimento posterior da vítima excluiria o tipo penal do estupro.

Pode ocorrer a situação contrária: o início da relação sexual consentida e durante a relação sexual a vítima alterar a sua vontade. Após ter essa recusa séria e objetiva, o agente continua a praticar o crime mediante constrangimento, violência ou grave ameaça. Em que pese no início haver o consentimento da vítima, mesmo assim o agente responderá pelo crime de estupro. Houve o estupro.

Na primeira situação é que pode existir alguma dúvida: houve estupro inicial, mas a vítima consentiu a seguir. A doutrina considera que houve um fato atípico.

5. Conjunção carnal e atos libidinosos praticadas no mesmo contexto fático configuram único crime de estupro?

Por exemplo, o agente, mediante grave ameaça, obriga a vítima a retirar a sua roupa e começa a praticar sexo oral na vítima. Após praticar sexo oral contra a vontade da vítima, ela foi constrangida a isso mediante grave ameaça, ele pratica conjunção carnal. Praticou atos libidinosos e conjunção carnal.

Trata-se de crime único obviamente desde que praticado no mesmo contexto fático. A dosimetria da pena obedecerá ao número de atos praticados.

“As jurisprudências do STF e do STJ consolidaram-se no sentido de que o crime previsto art. 217-A, do Código Penal – CP, é **de tipo misto alternativo**. Ou seja, quando as condutas correspondentes a "conjunção carnal" e a "outro ato libidinoso" forem praticadas em um **mesmo contexto fático, contra a mesma vítima**, permitem o reconhecimento da ocorrência de crime único.” HC 306085/SP, 09/08/2016 e AgRg no HC 252144/SP, 07/03/2017.

O crime do artigo 217-A é de estupro de vulnerável, mas pode ser feita a analogia com o crime de estupro.

6. Prostituta pode ser sujeito passivo do crime de estupro?

Sim, não há qualquer diferenciação com relação a isso. A prostituta combinou com o cliente a prática de conjunção carnal. No quarto do motel, ela desiste. O agente, mediante grave ameaça, pratica essa conjunção carnal com ela, ou então a prostituta que combina a prática



10m



15m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

de conjunção carnal, mas não sexo anal. O agente, mediante grave ameaça, constrange a prostituta a praticar o ato libidinoso – com certeza configura-se crime de estupro em ambas as situações.

7. Marido que constrange, mediante violência ou grave ameaça, sua esposa à prática de conjunção carnal ou ato libidinoso pratica estupro?

Sim. Há muito tempo não era considerado estupro – considerava-se que o marido estava acobertado por uma excludente de ilicitude, exercício regular de direito. Existe um instituto, denominado débito conjugal, que é vigente até hoje: quando se casa com uma pessoa, há um pressuposto de que haja relações sexuais. Existindo esse débito conjugal e a esposa não estando disponível a qualquer momento, o homem pode forçá-la, constrangê-la mediante violência ou grave ameaça à prática do ato sexual. Obviamente isso não existe mais, dizia-se ser o exercício legal do direito em razão do débito conjugal. Atualmente, em que pese ser reconhecido por vários doutrinadores que o débito conjugal relacionado aos atos sexuais ainda está vigente, não há que se falar nessa possibilidade para o reconhecimento de uma excludente de ilicitude quando houver o estupro do marido em relação à sua esposa. Será sim crime de estupro e ele responderá pelo crime de estupro.

8. Estupro praticado por dois agentes em conluio, contra uma vítima, no mesmo contexto fático (“curra”). Quais crimes são praticados?

Dois agentes em conluio, um segura a vítima enquanto o outro a estupra, se revezam. Os agentes, cada um deles, responderão por dois crimes: por estupro, que ele próprio praticou, e pelo estupro que o outro praticou (coautoria ou partícipe, depende da situação). Se forem três, serão três crimes de estupro praticados por cada um deles (pelo estupro que eles próprios praticaram, bem como, pelo estupro praticado pelos demais agentes).

9. O estupro se consuma com a prática de atos libidinosos distintos do dolo final do agente?

Supondo-se que o dolo do agente seja praticar a conjunção carnal. Um homem ataca uma mulher na rua e a leva para um terreno baldio – utiliza-se mais o homem como exemplo porque é mais comum que este seja o ativo e a mulher o passivo, mas há casos de mulheres que praticam estupro contra homens da mesma forma.

No terreno baldio, o homem começa a arrancar a roupa da vítima. Nesse momento chega a polícia e interrompe: ele não conseguiu praticar nenhum ato libidinoso nem a conjunção carnal, é tentativa de estupro.

Numa outra situação, o agente ataca essa mulher. O dolo dele é praticar a conjunção carnal, entretanto, no momento em que está tirando a roupa da mulher, ele começa a tocar os seios da

ANOTAÇÕES

mulher, tocar e beijar as partes íntimas dela. Ele não praticou a conjunção carnal, que era sua intenção, mas praticou atos libidinosos. Praticando esses atos libidinosos, antes de praticar a conjunção carnal, a polícia chega e interrompe o estupro. Não houve a conjunção carnal, que era o dolo, mas houve a prática de atos libidinosos que já configura o crime de estupro.

“O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o momento consumativo do crime de estupro de vulnerável ocorre com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes, no caso, em mostrar o pênis e passar as mãos na genitália das duas menores – por baixo da roupa de uma e dentro da fralda da outra –, além de tentar beijar um das vítimas na boca.” AgRg no REsp 1629726/RS, 19/04/2018.

Mais uma vez, embora a referência seja a estupro de vulnerável, essa situação está pacificada no que concerne a estupro de vulnerável. Com relação ao estupro há duas posições: uma que adota esse entendimento (o agente responde por estupro consumado, art. 213 do CP) e outra, mais garantista, que considera que houve estupro tentado porque o dolo do agente era voltado para a conjunção carnal.



CAPÍTULO I – DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL ESTUPRO

Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso:

Pena – reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.

§ 1º Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos:

Pena – reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.

Essa lesão corporal pode ser grave (art. 129 § 1º do CP) ou gravíssima (art. 129 § 2º do CP). As lesões corporais leves e as vias de fato são absorvidas pelo estupro na modalidade simples. A lesão corporal deve ter natureza **preterdolosa**: dolo na conduta, culpa no resultado, dolo no antecedente, culpa no consequente – a intenção do agente era praticar o estupro, como decorrência desse estupro se gerou uma lesão corporal grave ou gravíssima, o agente responderá pela qualificadora, pelo estupro qualificado. O dolo do agente não era causar lesões. Se o dolo do agente for praticar um estupro e praticar uma lesão corporal grave ou gravíssima ele responderá por concurso material, não pelo estupro qualificado, mas com o estupro e a lesão corporal grave ou gravíssima, dependendo da situação.

ANOTAÇÕES



Se a vítima tiver mais de 14 anos, mas for menor de 18 anos, será estupro (art. 213 do CP). Em razão da idade da vítima, haverá uma qualificadora.

Se a vítima for maior de 18 anos o estupro será simples (art. 213 do CP). Se a vítima de um estupro é maior de 14 e menor de 18 anos, o estupro será o qualificado no § 1º. Se a vítima for menor de 14 anos (art. 217-A do CP), configura-se estupro de vulnerável.

Há um absurdo legislativo: imaginando que a vítima tem 14 anos, fez 14 anos no dia de hoje e na data de hoje ela é estuprada. Não é estupro de vulnerável porque ela tem mais do que 14 anos. O estupro qualificado pela idade da vítima é a vítima maior de 14 anos e menor de 18 anos.

A lei deveria ter estabelecido: “se a vítima tiver idade igual ou superior a 14 anos”. Em Direito Penal analogia em *malam partem* não é permitida.

É um absurdo na lei que já deveria ter sido corrigido, mas não foi até hoje.

§ 2º Se da conduta resulta morte:

Pena – reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos

Haverá, obviamente, natureza preterdolosa, a intenção do agente não é matar a vítima, é estuprar a vítima. Em razão da violência empregada, a vítima morre. O agente responde pelo estupro qualificado pela morte com a pena máxima prevista no Código Penal brasileiro.

Se, por um acaso, há um autor que estupra a vítima e, após estuprar, decide matá-la – é uma hipótese completamente diferente porque no estupro a natureza do resultado morte é preterdolosa, o agente age com dolo no estupro, com dolo na violência, mas há culpa quando se fala no resultado morte: ele não queria matar a vítima.

Se a intenção do agente é estuprar e matar a vítima, responderá pelos dois crimes em concurso material: pelo estupro e, também, pelo homicídio.

Se ele estupra a vítima e a mata para ocultar o estupro, para que ela jamais venha a denunciá-lo, responde pelo estupro e por homicídio qualificado pela conexão (art. 121, § 2º, inciso V do CP): ele cometeu o homicídio para ocultar outro delito.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
